

1500373-08.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500373-08.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-08.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036947/2022 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 22901059 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2036947 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DA SILVA MAGALHAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Gabriel da Silva Magalhães foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, pois, segundo denúncia (fls. 74/75), no dia 08/02/2022, por volta das 18 horas, na Rua Jaci, nº 494, Jardim Josefina, em Franco da Rocha, o réu trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 2,59g de cocaína em forma de "crack", fracionada em 09 unidades, 41,49g de tetrahidrocannabinol, acondicionado em 16 porções, e 35,19g de cocaína, dividida em 53 tubos plásticos, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 15) e laudo químico-toxicológico (fls. 61/63), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fl. 90), o réu apresentou defesa prévia (fls. 95/96), sendo a denúncia recebida em 09/03/2022 (fl. 76).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final da instrução.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e aplicação

de pena mínima, subsidiariamente.

É o relatório.

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do: boletim de ocorrência (fls. 02/04), do auto de exibição de apreensão (fl. 15) e laudo toxicológico definitivo (fls. 61/63), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos. Disse que estava no local do fato quando alguém dispensou uma sacola com a chegada dos guardas municipais. Como ficou assustado, pegou a sacola do chão e saiu correndo, sendo abordado posteriormente. Com a abordagem, caiu ao solo ao ser contido, sabendo, posteriormente, que o conteúdo portado eram entorpecentes. Declara que não está machucado, foi atendido na UPA local e dispensado. Não tem advogado e não sabe indicar qualquer contato para comunicação de sua prisão. Estudou até a 5ª série, é artesão. Não tem filhos e reside com seus familiares. Já foi preso por tráfico de drogas (fl. 08).

Em juízo, o réu disse que os fatos são falsos. Disse que foi ao local para comprar drogas. Quando chegou ao local, viu o traficante. Quando os guardas chegaram, o traficante correu com uma sacola na mão na e deixou outra no chão. Saiu andando pelo escadão devagar e foi preso pelos guardas. Não conhecia os guardas. Tentou escapar dos guardas porque ele seria forjado. Faz uso de maconha. Trabalhava fazendo artesanato fazendo peças para vender. Faz uso apenas de maconha. Não pegou a sacola com drogas. Tem tatuagem de carpa há tempo e não faz parte do PCC. Sua versão não se encontra em consonância com o cenário probatório obtido.

A testemunha William da Silva Dias (GCM), perante a autoridade policial, disse que na data dos fatos prosseguia com patrulhamento rotineiro na cidade de Franco da Rocha/SP e ao chegar na Avenida Jaci, local conhecido pelos policiais pela grande incidência de vendas e consumo de drogas, avistaram um indivíduo, pardo, jovem, estatura mediana, que passou imediatamente a correr com uma sacola plástica nas mãos assim que avistou a guarnição. Dada à fundada suspeita, os guardas acompanharam o suspeito por alguns metros até que conseguiram interceptá-lo. Nada obstante, o indivíduo arremessou ao chão a sacola plástica que trazia consigo, jogando-se ao solo, sendo que começou a bater seus braços e pernas contra a testemunha, que a esta altura tentava controlar a situação. As tentativas frustradas de fuga provocaram autolesões leves na região das pernas, peito e braços do indivíduo que estava sem camisa. Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse do suspeito, porém, ao analisarem o conteúdo da sacola outrora arremessada, localizaram substâncias semelhantes a maconha, crack e cocaína, além de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas trocadas. O suspeito não apresentava documentos pessoais e mediante a situação supra narrada foi encaminhado à UPA de Franco da Rocha para tratar das autolesões e, em seguida, conduzido a unidade policial (fl. 06).

Em juízo, a testemunha disse que estava em patrulhamento em local conhecido de tráfico de drogas. O réu, ao ver a viatura, empreendeu fuga por um escadão. Ele estava parado com uma sacola em mãos. O réu resistiu à prisão. Dentro da sacola foram encontrados os entorpecentes. O réu também portava R\$20,00. O réu disse que estava realizando a venda de drogas desde a parte da manhã naquele dia. Não conhecia o réu antes desses fatos.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Robson Rosa da Silva (GCM). Disse que estavam em patrulhamento em ponto conhecido pela venda de drogas. O réu empreendeu fuga ao ver os guardas municipais. O depoente correu atrás do réu. O réu resistiu à prisão. Em um dado momento caiu e derrubou a sacola com os entorpecentes. Conseguiu se desvencilhar do guarda e foi pego novamente, tendo entrado em luta com o depoente. Teve ajuda de seu colega. Na sacola localizou crack, cocaína e maconha. Não conhecia o acusado antes desses fatos.

Preliminarmente, não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais.

Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria

de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP).

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva. É cediço que o art. 144, §8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da posição consolidada pelos Tribunais Superiores:

"Nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03/08/2017). No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, §8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, inc. IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, inc. XIV).

Neste caso, os guardas presenciaram a atitude suspeita do denunciado, que ao avistar a viatura fugiu correndo e não acatou a ordem de parada, estando de posse de sacola com entorpecentes em ponto de conhecida traficância. Assim, era presumível que ele pudesse estar cometendo um delito, não tendo sido a ação dos guardas decorrente de qualquer investigação prévia, sendo evidente que a atitude do réu não é a que se espera de um transeunte ao avistar agentes do Estado.

Ainda quanto aos guardas municipais ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar o réu de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer os conheciam e nem tinham passagem policial.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais. Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo." (TACrim, 12ª Câmara, rel. Des. João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Não é crível que os guardas pudessem ter em seu poder tamanha quantidade e diversidade de drogas somente para imputar responsabilidade ao acusado, destacando que a defesa não apontou qualquer animosidade entre o réu e os guardas, de maneira que não há nada que mitigue a validade de seus depoimentos, resultando a autoria do réu incontroversa.

Nem se fale que a prova é problemática seja pela ausência de outros depoimentos estranhos aos órgãos de segurança ou ainda pela falta de imparcialidade do testemunho dos guardas. Atualmente é notório que, nos crimes de tráfico, os testemunhos de civis, alheios aos quadros policiais, são cada vez mais raros, ante o medo que norteia a população no tocante ao citado delito, sentimento compreensível pela estruturação advinda dele, fomentada pelo grande lucro envolvido e pelo conhecido Código de Ética, principalmente nos locais mais humildes, o que

culmina, conseqüentemente, com a perda da própria vida dos colaboradores.

Dessa forma, deve o depoimento dos guardas ser tido como outro qualquer, ou seja, para desacreditá-lo, é necessário demonstrar a invalidade concreta e não apenas suposta. E a própria versão apresentada pelo réu - negativa de autoria - é inaceitável e ficou divorciada do conjunto probatório.

Portanto, o testemunho dos guardas merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os guardas mentiram ou inventaram a diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na fase policial e na instrução judicial.

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana.

A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos GCMS ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução.

Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, diante da ausência de informações seguras sobre as reais condições econômicas do réu, considerando-se que o réu é primário (fls. 79/80).

Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

É de se esclarecer que não é mais possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido foi fixada a tese no julgamento do repetitivo quanto ao REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180 junto ao STJ: " É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006".

Pessoalmente, este juízo discorda da tese jurisprudencial fixada, eis que o fato do acusado possuir inquéritos com datas próximas relativos à apuração de crimes da mesma natureza, como nos autos, é evidência de que este se dedica ao tráfico como meio de vida.

Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

No caso em curso, o réu responde a outro feito por tráfico de drogas que teria ocorrido apenas 05 (cinco) meses antes dos fatos descritos na denúncia (conforme fl. 79 - autos nº 1502059-69.2021.8.26.0544). Não entendo que seja possível ao juízo ignorar tais evidências de comportamento endêmico criminoso, privilegiando o réu nos mesmos moldes daqueles que não ostentam qualquer outro registro criminal. Ainda, é de se pontuar que, em casos como este em curso, ainda que o acusado venha a ser condenado futuramente por crime de tráfico nos autos relativos a fatos anteriores a este, sequer seria possível o afastamento da causa de diminuição de

pena nessa ocasião, eis que não será possível a valoração de fatos posteriores para esse fim. Tal fato, portanto, implicaria em dupla redução de pena a pessoa que foi presa, supostamente, pelo mesmo crime em intervalo curto de tempo.

No entanto, tendo sido a tese fixada em sede de recurso repetitivo, não resta alternativa que não a sua aplicação por esta magistrada, em respeito ao sistema de vinculação de precedentes.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), observando (na fixação do quantum dessa redução) o que prescreve o art. 42 da mesma lei, tornando definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada, uma vez que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo.

Neste sentido a jurisprudência:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de 'habeas corpus' para afastar a natureza hedionda de tal delito.” (HC 118533, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJE de 19.9.2016) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO”. INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC 111.840). POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.”

De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à acusada por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Nos termos dos artigos 49, §1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida no regime aberto, uma vez que o réu é primário, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno Gabriel da Silva Magalhães como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade imposta à acusada por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do

que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade face a pena aplicada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto, portanto, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Defiro a gratuidade ao réu.

P.I.C.

Franco da Rocha, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA